

1503125-11.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... com o caso, responder pela "participação no crime de tráfico (arts. 33, caput e § 1º, e 34)."451 Esse entendimento peca por consentir com a punição muito mais severa do agente que colabora eventualmente com informações prestadas a um traficante solitário (partícipe do tráfico), em relação àquele que colabora do mesmo modo com uma associação para o narcotráfico (Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503125-11.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503125-11.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259480/2021 - 01º D.P. CUBATÃO, 20419481 - 01º D.P. CUBATÃO, 549/21/228 - 01º D.P. CUBATÃO, 2259480 - 01º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR DE MOURA IGLESIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra JOÃO VICTOR DE MOURA IGLESIAS, tendo-o por incurso nos arts. 33, caput, e 35 da lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, imputando-lhes os seguintes termos: [a] consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na manhã de 21 de setembro de 2021, por volta das 08h, na rua Jonas de Souza, n. 11, Nova República, nesta cidade e comarca de Cubatão, estava associado com o adolescente inimputável Samuel Jackson de Jesus Silva para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas; [b] consta ainda que, na mesmas condições de tempo e lugar, juntamente com o adolescente inimputável Samuel Jackson de Jesus Silva, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 16 porções de maconha, 18 porções de cocaína e 23 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de rádio comunicador HT e R\$ 80,00 em espécie, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 81/83.

O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva [fls. 46/49]. Notificado e citado, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 [fls. 125], o réu, por intermédio de Defensor nomeado, apresentou resposta [fls. 138].

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 [fls. 141 e 162].

Designada audiência, na qual foram ouvidas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu, com registro em mídia digital.

Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnano pela sua condenação nos termos da peça acusatória, discorrendo sobre a dosimetria.

Por sua vez, em seus memoriais, a Defesa do réu pleiteou sua absolvição, sustentando não existir prova suficiente para a condenação [CPP, art. 386, VII] e, em caso de condenação, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante [fls. 01/04], pelo boletim de ocorrência [fls. 05/07], pelo auto de apreensão e exibição [fls. 08/09], pelo laudo de exame de constatação preliminar [fls. 10/11], bem como pelo laudo definitivo de perícia criminal (Química Forense) [fls. 154/156], positivos para cocaína em relação ao material apreendido, além da prova oral produzida em juízo.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pelos depoimentos de testemunhas.

A tese defensiva, como se verá, está isolada nos autos.

Albino Arias Costa, investigador de polícia, em diligência com viatura descaracterizada em local conhecido ponto de tráfico de drogas visualizou João Victor com um rádio na mão e Jadson com uma sacolinha. Estavam próximos.

Estacionaram a viatura um pouco mais a frente e se aproximou dos indivíduos a pé. João Victor estava no papel de olheiro. Deslocou-se a pé com uma nota de dez reais na mão, aparentando ser usuário em busca de algum entorpecente. Ao se aproximar, o menor questionou o que queria e o olheiro, que seria João Victor, falou que era pó. O indivíduo que estava com a droga foi abordado e contido enquanto João Victor tentou empreender fuga. Na sacola havia aproximadamente 15 porções de maconha, 20 de cocaína e umas 25 de crack. O rádio lançado foi recuperado. João Victor não estava com drogas, a droga estava na mão do menor. João Victor estava com rádio comunicador na entrada da favela para evitar o êxito da polícia, sendo modus operandi que se repete por um tempo. Já viu João Victor outras vezes, mas nunca foi preso anteriormente por conseguir se favorecer desse alerta para dispensar os objetos ilícitos. Informalmente, o menor recebe uma pequena porcentagem, sendo a participação maior do dono do horário [responsável por pagar os demais participantes]. Reafirma já ter visto João Victor na área, mas não traficando. Não se recorda de ter ido até a residência de João Victor. Não tem como afirmar se João Victor participa de alguma organização criminosa, mas que já foi visto outras vezes no local de traficância. No local também tem bastante usuário de drogas. Esclareceu ter visualizado o momento em que João Victor jogou o rádio comunicador.

Eduardo de Santos Araújo, em igual sentido, investigador de polícia, disse estar em operação com viaturas descaracterizadas em local conhecido por tráfico de drogas. Verificou o menor, circunstância ignorada. João Victor trazia consigo rádio de comunicação e o adolescente não estava com nada. Desembarcaram e foram em direção dos indivíduos. O menor quando viu Albino tirou o saco de drogas dentro da blusa. João Victor jogou o rádio para cima e tentou correr, sendo detido em seguida. Teve a conclusão de que João Victor era olheiro por causa do rádio de comunicação.

Indagou o que o réu estava fazendo, mas não se recorda do momento. Não conhecia João Victor. Na época dos fatos, realizava várias diligências no local dos fatos e que as pessoas que ficam na biqueira são renovadas.

O réu João Victor negou os fatos. Informou que estava no local com o intuito de

usar drogas. Afirma que estava com um rádio comunicador. Recebeu uma proposta de estar com o menino e, em troca, receberia drogas. Permaneceu com o rádio em mãos por cerca de duas horas, logo de manhã foi preso. O rádio em mãos era para escutar, mas não tinha ninguém para falar. Vieram dois policiais descaracterizados, um estava com capuz e o outro com roupa "de firma". Um deles "pegou" o adolescente e o outro foi em sua direção. Não correu, ficou sentado. Estava a cinco metros de distância do adolescente. Não sabia que o indivíduo era menor, soube no momento. O menor estava vendendo droga. Estava morando na casa de sua sogra, próximo ao local em que foi preso. Atualmente está trabalhando. Está arrependido. Os policiais não possuem motivo para incriminá-lo injustamente.

Essa é a prova oral constante dos autos.

Consigne-se que os inquiridos expuseram satisfatoriamente os fatos, sendo certo que os relatos são dignos de credibilidade, não se percebendo qualquer tentativa de falsear a verdade, porque convincentes e provenientes de pessoas cuja idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de possuíam interesse em prejudicar o acusado, a quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa incriminação.

Interrogado em Juízo, o réu negou a veracidade da imputação. Alegou que não estava no local para o exercício do tráfico, mas para adquirir drogas. Recebeu proposta de permanecer no local para que, ao final, recebesse drogas para uso. Passadas algumas horas foi detido pelos policiais.

A negativa inconsistente não infirma a versão das demais testemunhas, tornando imperiosa a responsabilidade criminal do réu, anotando-se que os policiais militares corroboraram em juízo a dinâmica dos fatos constante da denúncia, no sentido de que o réu estava em ponto conhecido da região pelo expressivo movimento do tráfico de drogas. Os policiais, na ocisão, estavam descaracterizados, facilitando, assim, o flagrante. Viram o réu, juntamente com um adolescente, no exercício do tráfico de drogas, tendo sido abordados no momento, sendo encontradas as drogas descritas no laudo de fls. 154/156 [16 porções maconha, 18 porções cocaína e 23 porções crack, fls. 08/09]. Na ocasião, ainda, lograram êxito em apreender um rádio para comunicação com os demais parceiros de traficância, conforme laudo de fls. 157/159.

Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. Aliás, os atos funcionais do servidor público são presumidos verdadeiros [CF, art. 37].

Assim, não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, "[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" [STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996]. Por oportuno, confira-se: "Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública". [TJSP, Ap. n. 0000604-19.2016.8.26.0545, rel. Des. Herman Herschander, j. 07.12.2017]

A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade própria e prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.

No mais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal [CPP, art. 155].

Outrossim, a legislação processual penal em vigor não obriga a participação de testemunhas civis no momento em que ocorre a prisão em flagrante, mostrando-se, pois, legítimo o procedimento dos agentes de segurança pública. Aliás, notória é a dificuldade de encontrar pessoas que, tendo presenciado o estado de flagrância, estejam dispostas a testemunhar contra narcotraficantes.

Induvidosa a apreensão de entorpecentes imputáveis ao réu e ao terceiro adolescente.

Desse modo, o fato alegado pelo réu [ter ido ao local de traficância para comprar drogas para consumo pessoal], sem repercussão em elemento de prova objetivo ou subjetivo, não gera dúvida objetiva razoável em seu favor. Com efeito, não carreu aos autos qualquer indício de sua alegação, incompatível com o depoimento dos policiais civis ouvidos. Nesse sentido, já se decidiu que “de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado.” [STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 4.376/SP, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.1.2005]. Decerto, os núcleos do tipo ter em depósito e guardar, constam do artigo 28 e do artigo 33, ambos, da Lei nº 11.343/06.

A própria Lei em referência, no entanto, em seu art. 28, §2º, e art. 52, I, apresentou critérios distintivos e com fundamento neles a finalidade da traficância é inafastável.

Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção da destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do crime: [a] a quantidade e modo de acondicionamento dos entorpecentes; [b] o rádio encontrado em sua posse; [c] a variedade de drogas postas à disposição de quem queira comprar; [d] a narrativa dos policiais civis.

Inviável, pois, acolher-se a pretensão absolutória.

A desclassificação para informante colaborador é imperiosa, por isonomia.

Com efeito, a colaboração em comunicar grupo, organização ou associação destinada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes se configura pelo ajuste prévio no uso de rádio comunicador, com intuito de garantir a impunidade dos traficantes que realizam a efetiva mercancia ilícita perante agentes do Estado que buscam combater a prática delitiva.

Leciona Guilherme de Souza Nucci que “(...) o intuito do legislador, ao adotar no tipo penal do artigo 37, da Lei nº 11.343/06, a teoria pluralista do concurso de agentes não foi a de alcançar aqueles que exercem funções habituais no tráfico, como o 'olheiro', pois este é coautor da conduta descrita no artigo 33, mas sim aqueles que normalmente não integram a associação criminosa, em suas diversas funções hierárquicas, mas acabam colaborando com informações privilegiadas e estratégicas para o exercício da traficância(...)” [Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Editora Forense, 8ª edição fl. 367]. Outrossim, “(...) o informante presta um auxílio aos associados no tráfico que às vezes é considerado secundário, mas na realidade não é. Avisar àqueles que atuam no tráfico que a polícia realizará uma operação e com isso impossibilitar a prisão em flagrante dos agentes do tráfico e também deixar a vida dos policiais mais vulnerável não é auxílio secundário. Não se pode confundir a participação simples como soltar “pipa” ou “papagaio” e fogos de artifício advertindo os associados no tráfico com uma ajuda que não é importante” [RANGEL, Paulo; BACILA, Carlos Roberto. Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 125].

A prova dos autos assegura que o réu estava em local conhecido pelos policiais como ponto estratégico utilizado para venda de drogas exercendo função de “olheiro”, participação substancial para assegurar o êxito da efetiva empreitada criminosa levada a efeito por adolescente, quem trazia consigo e guardava entorpecentes, típica conduta de tráfico.

Inviável, em princípio, acolher-se a pretensão desclassificatória, porque correta a tipificação pelo tráfico, mediante a norma de extensão do art. 29 do Código Penal, não havendo que falar na falta ou insuficiência de provas ou desclassificação da

conduta do réu para o delito do art. 37 da Lei nº 11.343/06, mormente porque a informação se dá a traficante solitário, e não a “grupo, organização ou associação”.

E essa distinção legal viola a isonomia e proporcionalidade, conforme lição doutrinária bastante: “A tipificação da colaboração episódica como informante de um traficante isolado – pessoa que se dedica sozinha ao narcotráfico – gera intenso debate na doutrina e na jurisprudência. Existem três posições sobre o assunto: 1ª posição: O fato é atípico. Se a colaboração informativa for prestada em favor de um único traficante, e não para um grupo, organização ou associação, “a conduta do agente será atípica em face deste art. 37, diante da interpretação restritiva da lei penal.”⁴⁵⁰ 2ª posição: Não há o crime do art. 37 da Lei de Drogas, mas pode o agente que colabora como informante de apenas um traficante, de acordo com o caso, responder pela “participação no crime de tráfico (arts. 33, caput e § 1º, e 34).”⁴⁵¹ Esse entendimento peca por consentir com a punição muito mais severa do agente que colabora eventualmente com informações prestadas a um traficante solitário (participe do tráfico), em relação àquele que colabora do mesmo modo com uma associação para o narcotráfico (Lei 11.343/2006, art. 37). 3ª posição: Defende a possibilidade de aplicação, por analogia in bonam partem, do art. 37 da Lei de Drogas ao colaborador eventual que presta informações ao traficante solitário. É o nosso entendimento, também adotado por Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho: ‘Não será atípica, pois em razão do disposto no art. 29 do CP, ele estará auxiliando o traficante e, como tal, deverá responder pelo delito por este praticado, como partícipe. Se, por exemplo, presta informações para um traficante solitário sobre o melhor local para a venda de drogas ou para a aquisição de drogas, responderá pelo crime de tráfico posteriormente executado. Porém, tal solução fere de morte o princípio da isonomia, pois neste caso receberá pena de cinco a 15 anos, enquanto se tivesse contribuído com um grupo de traficantes receberia pena de dois a seis anos. Não há razão para distinguir, principalmente porque a situação de quem contribui com apenas um traficante é menos grave do que aquela de quem contribui com um grupo de traficantes. A solução, justamente por isto, é a aplicação da analogia in bonam partem, de forma a ser alcançado pelo presente tipo penal também aquele que contribui com apenas um traficante, em razão da lacuna da Lei.’⁴⁵² [MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinícius. Lei de Drogas - Aspectos Penais e Processuais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2021, e-book].

A imputação fática permite qualificação jurídica distinta daquela indicada na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Trata-se da emendatio libelli que não cerceia a defesa, porquanto o réu se defende de fatos e não da capitulação jurídica.

Conforme acima fundamentado, a prova dos autos assegura a prática criminosa descrita no art. 37 da Lei n. 11.343/06.

Passa-se ao exame da adequação típica do crime de associação para o tráfico.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige-se, além do concurso mínimo de duas pessoas, prévio ajuste entre agentes que comunguem o propósito de, reiteradamente ou não, praticarem as condutas previstas nos arts. 33, caput e §1º, e 34, da Lei n. 11343/2006, com certo grau de estabilidade e permanência, elemento subjetivo específico exigido para distinção de mera prática delitiva em concurso de agentes, sendo prescindível a efetiva realização das condutas criminosas referidas, por se tratar de crime formal e de perigo abstrato. A prova dos autos não assegura o preenchimento desses requisitos, porque a realidade retratada pela prova é inidônea para configurar um programa delinquencial estável e duradouro com meta comum de traficância, comprometendo a paz e a saúde públicas imputáveis aos réus.

Nada além da prisão no local portando rádio comunicador há nos autos. O réu negou estabilidade e permanência, nada refutando sua alegação.

A própria acusação requereu condenação com o seguinte argumento: “Ainda, quanto ao crime de associação ao tráfico, restou evidenciado que o menor era o responsável pela venda direta e guarda do dinheiro proveniente da traficância, enquanto o réu era o responsável pela abordagem do usuário e avisar eventual aproximação policial”

[fls. 173].

Assim, "Havendo dúvidas sobre o vínculo associativo dos réus, estável e permanente para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, impossível a condenação" [Ap. n. 0012135-83.2011.8.26.0220, rel. Des. J. Martins, j. 4.12.2014].

Imperioso o reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, o qual se configura, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci quando "envolver (trazer o menor para cenário das drogas, sob qualquer pretexto) ou visar (ter o menor como meta para uso de drogas). Por isso, o menor pode ser participante ou vítima do tráfico ilícito de entorpecentes" [Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, v. 1, 8ª ed., Forense, p. 376].

A atuação do réu em conjunto com o adolescente foi amplamente comprovada nos autos. Aliás, o próprio réu reconheceu a participação do adolescente na prática do tráfico de drogas.

Sem ignorar posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal, frise-se que a condição adolescente não é fato controvertido nos autos, o réu reconhece a menoridade e há documento público suficiente à comprovação dessa realidade [cf. Súmula n. 74 do STJ; fls. 20-21].

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, notadamente aquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é normal ao tipo. O acusado não registra maus antecedentes. A conduta social e personalidade ["deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio accidental na vida do réu" [Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588], à míngua de elementos de provas objetivas desabonadores, são favoráveis ao réu. O motivo do crime integra sua definição típica, e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As consequências do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. Assim sendo, pena-base no mínimo legal.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 [crime envolvendo adolescente], razão pela qual aumento de 1/6.

A pena definitiva é de 2 anos e 4 meses de reclusão com 350 dias-multa.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea a c/c § 3º, do Código Penal, mormente considerando a participação de adolescente em típica conduta de tráfico de entorpecentes variados em local ponto de tráfico.

À vista da primariedade do agente, ressaltando, ainda, que, confirmando a tendência jurisprudencial, o Senado Federal (art. 52, X, CF) publicou em 15 de fevereiro de 2012 a Resolução nº 5/2012, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (HC nº 97.256/RS), cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito [CP, art. 44, § 2º, segunda parte], fixando-as em prestação de serviço à comunidade (art. 46, CP) em entidade a ser designada pelo juízo das execuções penais (LEP, art. 66, V, a) e prestação pecuniária (art. 45, §2º, CP) no importe de um salário mínimo nacional a ser revertido em favor de entidade designada pelo juízo da execução.

Por oportuno, registre-se: "No universo de perversidade e desesperança alimentado pelo tráfico, há casos singulares que a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade em geral se revela mais eficiente na repressão e prevenção da criminalidade. São aqueles nos quais as circunstâncias do fato como a pequena

quantidade de entorpecente e, principalmente, as condições pessoais do agente muitas vezes primário e de bons antecedentes, inclusive com trabalho lícito ou ainda na fase estudantil, não evidenciam a periculosidade que o cárcere procura conter como medida extrema de proteção social. Nem todo delito de tráfico traz, insita, a gravidade ou potencial ofensivo que justifique o encarceramento do seu autor. Essa é uma verdade nem sempre admitida. Impõe-se, assim, quando cabível e “socialmente recomendável” para não fugir à literalidade do artigo 44, § 3º, do CP, resposta punitiva alternativa à prisão, verdadeira sanção pedagógica, considerada, porque não, a baixa periculosidade, a prematuridade do indivíduo ou, mesmo, a revelada potencialidade de se reintegrar à coletividade. Busca-se, enfim, a regeneração individual, sem descurar-se da retribuição estatal, mas evitando-se o cárcere, lugar que deve ser reservado a hipóteses em que a periculosidade suplanta a esperança ou a mera expectativa de ressocialização, ainda lembre-se um dos fins da reprimenda penal” [Ap. n. 0000406-95.2015.8.26.0551, rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 14.02.2017].

O local e a forma de cumprimento da pena serão definidas pelo Juízo da Execução. Fica o réu advertido de que no caso de descumprimento injustificado das restrições impostas, as penas restritivas de direitos serão convertidas em privativa de liberdade, conforme disposto no § 4º do artigo 44 do Código Penal, com seu recolhimento à prisão.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade, não se há falar em sursis, ressaltando-se a vedação prevista no do art. 44, caput, da Lei 11.343/06 [cf. RESp n. 1358147, rel. Min. Marilza Maynard, j. 18.4.2013].

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, em consequência:

[A] ABSOLVO JOÃO VICTOR DE MOURA IGLESIA da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

[B] CONDENO JOÃO VICTOR DE MOURA IGLESIA, qualificado anteriormente, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 350 dias-multa, no mínimo legal, por incurso nos artigos 37 da Lei 11.343/06.

Não estão presentes os pressupostos fáticos de cabimento da prisão preventiva.

Poderá o réu recorrer em liberdade, vez que respondeu em liberdade ao processo e não se encontram presentes os pressupostos da prisão cautelar.

Dê-se à droga apreendida a destinação prevista no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, preservada quantidade para eventual contraprova.

Não estão presentes os pressupostos fáticos de cabimento da prisão preventiva.

Por fim, indiscutível que o dinheiro e os bens apreendidos eram provenientes do tráfico ou empregados para a prática. Nessa situação, com fundamento no artigo 63 da Lei 11.343/2006, viável o perdimento do dinheiro e dos bens apreendidos em poder dele.

Inaplicável à hipótese a fixação do valor mínimo para reparação de danos [CPP, art. 387, IV] por se tratar de crime vago.

Após o trânsito em julgado: [a] expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; [b] notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de dez dias, nos termos do art. 50, caput, do Código Penal [TJSP, Provimento CG n. 11/2015]; [c] oficie-se o TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF; [d] oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Fixo os honorários advocatícios das patronas dos réus, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso e expedindo-se as competentes certidões.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo penal, ressaltando-se, como já se decidiu: “Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim e se conceder ou não a isenção reclamada (...)” [STJ, RESp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P. I. C.

Cubatão, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA